

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5485/2562

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

โจทก์

เด็กหญิง ส. โดยนาง อ. ผู้แทนโดยชอบ

ธรรม กับพวก

ผู้ร้อง

นาย ท.

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (18), มาตรา 3, มาตรา 277, มาตรา 279 วรรคสอง (เดิม)

ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ออกใช้บังคับ โดยมาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (18) ของมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา "(18) "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำ อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น" มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ความใหม่แทน แต่ความใหม่มิได้บัญญัติ ให้การใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นเป็นความผิดฐาน กระทำชำเรา ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เพียงว่า จำเลยใช้ลิ้นเลียอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 อีกต่อไป แต่การที่จำเลยใช้ลิ้นเลียอวัยวะเพศเป็นการกระทำที่ไม่สมควรทางเพศแก่ ผู้เสียหายที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดย ชู้เช็ดด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ ขัดขืนได้ตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคสอง (เดิม)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 279, 283 ทวิ, 317

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา เด็กหญิง ส. ผู้เสียหายที่ 1 โดยนางสาว อ. มารดาผู้แทนโดยชอบธรรม และนางสาว อ. ผู้เสียหายที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงิน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ทำละเมิดจนถึงวันจำเลยชำระเงินแก่ผู้เสียหายทั้งสองเสร็จสิ้น

จำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสี่, 279 วรรคสอง, 283 ทวิ วรรคสอง, 317 วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากมารดาเพื่อการอนาจาร จำคุก 5 ปี ส่วนฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยใช้อาวุธ ฐานกระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร การกระทำเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีโดยใช้อาวุธ อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกตลอดชีวิต เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุก

ตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) กับให้จำเลยชำระเงิน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้เสียหายทั้งสอง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเด็กหญิง ส. ผู้เสียหายที่ 1 ขณะเกิดเหตุมีอายุ 10 ปีเศษ และเป็นบุตรของนาย ย. กับนางสาว อ. ผู้เสียหายที่ 2 จำเลยเป็นน้ำของผู้เสียหายที่ 1

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 7 หรือไม่ สำหรับความผิดฐานปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน สิบห้าปีไปเสียจากมารดาเพื่อการอนาจาร ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณายืนตามศาลชั้น ต้น และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาขอ ให้ยกฟ้อง เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิด ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยใช้อาวุธ ฐานกระทำอนาจารเด็กอายุ ยังไม่เกินสิบห้าปี และฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจารหรือไม่ เห็นว่า ผู้เสียหายที่ 1 เป็นญาติกับจำเลย ก่อนเกิดเหตุไปมาหาสู่กันเป็นประจำ แม้ ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 อายุ 10 ปีเศษ แต่โตพอที่จะจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ ตนเองได้แล้ว เมื่อผู้เสียหายที่ 1 เบิกความว่า จำเลยพาผู้เสียหายที่ 1 ไปที่บ้าน

จำเลย บังคับให้ถอดเสื้อผ้า และใช้ลิ้นเลียอวัยวะเพศผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งผู้เสียหายที่ 1 ยังเป็นเด็กไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน หากไม่เป็นเรื่องที่ประสบมากับตนเอง คงไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเล่าให้ผู้อื่นฟังได้ หลังเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นมารดาฟัง ซึ่งโจทก์มีผู้เสียหายที่ 2 มาเบิกความยืนยันว่า ผู้เสียหายที่ 1 เล่าให้ฟังว่าถูกจำเลยกระทำชำเราและผู้เสียหายที่ 1 มีอาการกลัวจำเลยเมื่อมาที่บ้าน ในชั้นสอบสวนผู้เสียหายที่ 1 ยังให้การต่อหน้านักสังคมสงเคราะห์ พนักงานอัยการและผู้เสียหายที่ 2 ตามคำให้การชั้นสอบสวน เหมือนที่เบิกความในชั้นพิเคราะห์ยืนยันว่าถูกจำเลยพาไปที่บ้านแล้วใช้กำลังขู่เชือดและใช้ลิ้นเลียอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายทั้งสองมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่ผู้เสียหายทั้งสองต้องเบิกความปรักปรำจำเลยให้ต้องรับโทษ คำเบิกความของผู้เสียหายทั้งสองจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยใช้ลิ้นเลียที่อวัยวะเพศผู้เสียหายที่ 1 จริง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 วินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มิได้นำคำเบิกความของแพทย์หญิง ม. ประกอบผลการตรวจชั้นสูตรมาวินิจฉัย เห็นว่า แพทย์หญิง ม. เบิกความว่า ผลการตรวจร่างกายผู้เสียหายที่ 1 พบว่าอวัยวะเพศมีขนาดเล็ก ไม่ฉีกขาด ไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศถึงเยื่อพรหมจารี ไม่พบตัวอสุจิในน้ำเมือกในช่องคลอด หากมีการสอดใส่อวัยวะเพศของจำเลยเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 น่าจะทำให้เยื่อพรหมจารีฉีกขาด ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงฟังเป็นคุณแก่จำเลย โดยไม่อาจรับฟังว่า จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 โดยสอดใส่อวัยวะเพศของจำเลยเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 มาลงโทษจำเลย แต่ยังรับฟังได้ว่าจำเลยใช้ลิ้นเลียที่อวัยวะเพศผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นการกระทำชำเราโดยใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศของผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงวินิจฉัยความเห็นของแพทย์หญิง ม. ประกอบรายงานการตรวจร่างกายผู้เสียหาย

ที่ 1 ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้ว่า จำเลยใช้ลั่นเลี้ยวที่อวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 จริง มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานกระทำชำเราหรือไม่ เห็นว่า ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ออกใช้บังคับ โดยมาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (18) ของมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา "(18) "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น" มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความใหม่แทน แต่ความใหม่มิได้บัญญัติให้การใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นเป็นความผิดฐานกระทำชำเรา ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เพียงว่า จำเลยใช้ลั่นเลี้ยวอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 อีกต่อไป แต่การที่จำเลยใช้ลั่นเลี้ยวอวัยวะเพศเป็นการกระทำที่ไม่สมควรทางเพศแก่ผู้เสียหายที่ 1 จำเลยจึงมีความผิดฐานกระทำความอนาจารเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง (เดิม) และตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 279 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ความใหม่แทน แต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง (เดิม), 283 ทวิ วรรคสอง (เดิม), 317 วรรคสาม (เดิม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทำความอนาจารเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดย

ขู่เช็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ
ขัดขึ้นได้ และฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร การกระทำเป็น
กรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานกระทำอนาจารเด็กอายุ
ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยขู่เช็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้น
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขึ้นได้ อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี เมื่อรวมกับโทษฐานปราศจากเหตุอันสมควร
พรากรเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากรดาเพื่อการอนาจารแล้ว เป็นจำคุก 10
ปี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(อธิป จิตต์สำเร็จ-สนธิศาสตร์ เจตนั้วราพงศ์-เสมอดาว เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - นางสาวปวีรยา จินดาวสุ

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ387/2560

ต้น

หมายเหตุ